

안녕하십니까.

무더운 여름날 시험보시느라 고생 많이 하셨습니다.

제58회 상표법 시험 문제의 난이도는 상표법에서 총칙적인 규정인 상표의 사용과 상표법 전반에 걸쳐 활용되는 개념인 인식도에 대한 문제가 매우 큰 배점으로 출제된 점, 기존 경향과는 약간 상이한 문제가 출제된 점에 있어서 난이도는 어려운 것으로 판단됩니다. 또한, 수험생 여러분들께서 실제 시험장에서 느끼시는 체감 난이도 까지 고려하면 이번 시험은 매우 어려운 수준이었던 것으로 사료됩니다.

제58회 상표법 문제를 검토하면 문제 1에서 상표의 사용에 대한 단문형 문제가 출제되었고, 문제 2에서는 인식도에 대한 허니버터칩 판례에 기반한 단문형 문제가 출제되었습니다. 또한, 문제 2는 허니버터칩 판례에서 모티브를 얻었다 하여도 지금까지의 출제 경향과는 다소 거리가 먼 다소 <개념적인/이론적인> 내용으로만 물어본 거라 생경한 느낌도 들었습니다. 문제 3은 표장은 크로커다일이나 사실상 상표법 제119조 제1항 제2호에서 공부해야하는 모든 논점이 출제되었습니다. 또한, 문제 4는 사용에 의한 식별력 취득의 법리와 전통적으로 중요한 논점인 뉴발란스 판례, 등록 전후로 나누어 침해에 대한 조치를 묻는 문제가 출제되어 시간적 압박도 있었을 것으로 판단됩니다.

다시한번 말씀드리면, 이번 시험은 어려웠습니다. 그러니, 답안을 모범 답안의 논점을 모두 못 쓰셨다고 하여 너무 상심하지 마시기 바랍니다.

** 제공되는 답안은 한빛 상표법 강사들의 견해이며, 어떠한 법적 구속력 또는 이의신청의 근거가 될 수 없음을 명백히 밝힙니다.

[문제1]

I. 설문(1) - 1)에 대하여

1. 제2조제1항제1호에서의 사용

(1) 제2조제1항제1호의 의의 및 취지

- (2) 검토: 상표의 정의 규정상의 사용은 i) 조문규정상 상표의 구성요소 중 하나, ii) 2012년 개정 전 과거에는 선언적 의미에 불과하였으나, 이를 사용의사 없는 상표에 대한 거절의 근거 중 하나로 해석하는 견해가 있었고(특허법원 나홀로 판결 등), iii) 2012년 개정으로 제3조 제1항이 거절이유가 된 현행법상으로는 제3조 제1항과의 관계상 사용의사를 포함하는 개념으로 해석함(단, 사용의사가 없는 경우 실무상 제3조 제1항으로 거절). 이하 현행법상 제3조의 해석에 관한 판례를 검토함.

2. 제3조에서의 사용

(1) 제3조의 의의 및 취지

(2) 사용의사 판단기준 판례 (2017도7236)(★)

실제로 상표를 사용한 사실이 있거나 처음으로 사용하였는지 여부는 상표권 발생의 요건으로 볼 수 없다. 나아가 상표를 사용하려는 의사의 유무는 출원인의 주관적, 내면적인 의사를 중심으로 하되, 출원인의 경력, 지정상품의 특성, 출원인이 다수의 상표를 출원·등록한 경우에는 그 지정상품과의 관계 등과 같이 외형적으로 드러나는 사정까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

- (3) 검토: 제3조제1항본문을 중심으로 하되, 2012년 3월 15일 시행 개정법에서 거절이유 등에 해당하게 되었으며, 상표 등록 적격성 판단 중 하나로 최소한 현재 사용 또는 사용 예정 중인 것을 요구하게 된 사용주의적 요소가 가미된 규정(경우에 따라서 심사기준 상 사용의사 확인제도에 대하여 짚막하게 설명 가능)

Comment 2조1항1호에서의 사용은 “상표의 정의”를 구성하는 일 요소로, 3조에서의 사용은 “등록요건”을 판단하는 일 요소로 이해할 수 있습니다.

II. 설문(1) - 2)에 대하여

1. 등록 또는 심사와 관련된 규정

- 제2조제1항제2호 등 및 제2조제1항제11호/제2항
- **제33제2항(★)** - 제33조 제2항의 전제로 본질적 식별력 간단히 언급 가능
- 제34조제1항각호(특히, 제9호, 제11호 내지 제13호)
- 제47조(출원시의 특례)
- 제53조(우선심사)

2. 권리와 관련된 규정

- 제58조(손실보상청구권)
- 제89조

- 제90조
- 제92조
- 제98조, 제99조
- 제107조
- 손해배상과 관련된 규정(제108조 내지 제111조)(★)
- 제119조 및 제120조 (특히, 제119조제1항제3호(★))

Comment 사용과 관련된 규정을 다양하게 열거하였다면 충분한 점수를 받을 수 있을 것으로 생각합니다. 다만, “사용”을 직접적인 요건으로 하는 제33조제2항, 손해배상 관련 규정, 및 제119조제1항제3호는 의의 및 취지와 함께 서술하는 것이 필요한 문제로 보입니다.

Ⅲ. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재

乙의 사용이 甲의 등록상표에 대한 침해이고, 출원시 상표법 제34조 제1항 제7호의 거절이유가 예상되는바, 이하 乙의 조치를 검토함.

2. 조치1 - 제119조제1항제3호(★)

- (1) 제119조1항제3호의 의의 및 취지
- (2) 상표의 동일성 판단 (생략 사용 법리)
- (3) 불사용에 대한 정당한 이유
- (4) 소결

3. 조치2 - 양수협상/포기권유

Comment 다툼이 있을 수 있으나, 주된 쟁점은 제119조제1항제3호를 물은 것으로 생각합니다. 따라서, 조치를 위한 선결쟁점으로서 “침해여부”를 판단하는 것은 배점이 크지 않을 것으로 보이고, 제119조제1항제3호를 풍부하게 적은 답안이 좋은 인상을 줄 것으로 예상됩니다.

[문제2]

I. 설문(1)에 대하여

1. **상표의 인식도의 의의:** 상표를 사용함에 따라 수요자/거래자 사이에 당해 상표/상품이 알려진 정도

2. **상표의 인식도의 구분(★):** 무명상태/가치있는점유상태/특출인/주지/저명

3. 주지성 및 저명성(★): 상표가 사용된 상품에 관한 거래자 및 관련 수요자층 대다수에게 알려진 정도 VS 이종상품/이종영업에 걸친 일반 수요자층 대다수에게 알려진 정도

II. 설문(2)에 대하여

1. 제34조제1항제9호 - 주지성의 판단기준

- (1) 의의 및 취지
- (2) 주지성의 판단기준

그 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래실정이나 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 우선의 기준 (2010후2322 등)

2. 제34조제1항제11호 - 저명성의 판단기준(★)

- (1) 의의 및 취지
- (2) **저명성의 개념:** 그 상표가 수요자에게 널리 알려졌을 뿐만 아니라 그 상표를 사용한 상품이 갖는 품질의 우수성 때문에 수요자뿐만 아니라 일반 대중에게까지 양질감을 획득하고 있어 상품의 출처뿐만 아니라 그 영업주체를 표시하는 힘까지 갖게 된 정도 (2019허2837)
- (3) **저명성의 판단기준:** 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간·방법·양태와 거래범위 등을 고려하여 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부를 기준으로 판단 (2019후11787 등)
- (4) 검토: 주지성과 달리, 광고실적이 상당하더라도, 사용기간이 충분하지 않은 경우 저명성은 인정되기 어려움

3. 검토

- (1) 제34조제1항제9호 - 상품범위가 유사범위까지 인정
- (2) 제34조제1항제11호 - 상품범위가 이종상품까지 인정

4. 사안에의 적용 법리를 이용하여 甲의 상표의 인식도 판단

Comment 전체적으로 저명상표를 중심으로 내용을 서술하는 것이 적절해 보입니다. 특히, 상표의 저명성에 관하여 구체적인 정의 및 판단기준을 설시한 허니버터칩 사건을 중심으로 저명성을 고찰하는 답안이라면 좋은 점수를 받을 수 있을 것입니다. 나아가 소녀시대 사건도 간략히 언급 가능한 것으로 판단됩니다.

[문제3]

I. 설문(1)에 대하여

1. 제119조제1항제2호의 의의 및 취지

2. 대상상표로서의 적격이 있는지 여부 (인식도 관련 판례)(★)-(2012후1521)

- (1) 대상상표가 주지·저명한 것임을 요하지는 아니한다.
- (2) 대상상표는 특출인요건은 만족해야 한다
- (3) 소결

3. 사용권자의 동일 또는 유사 범위 내 사용 (유사범위 사용 관련 판례)(★)-(2012후1521)

(1) 판례

실사용상표가 등록상표를 타인의 상표(이하 ‘대상상표’라 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이다.

(2) 소결(실제 판례 문구임 - 이 부분을 응용하여 포섭할것)

이 사건 등록상표 “”의 통상사용권자들은 “”와 같은 상표(이하 ‘이 사건 실사용상표’라고 한다)를 사용하였는데, 이 사건 실사용상표는 악어 도형 부분이 옷감의 색상과 다른 연두색이나 초록색 등으로, 문자 부분이 옷감의 색상과 동일하거나 매우 유사한 색으로 자수(刺繡)가 되어 있는 등 그 색채에서 이 사건 등록상표와 차이가 있고, 그로 인하여 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와는 달리 전체적으로 악어 도형 부분만을 선명하게 보이도록 한 점 등을 고려할 때, 이 사건 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일성이 있다고 할 수 없고 유사한 상표라고 봄이 상당하다.

4. 대상상표와의 오인, 혼동 여부 (혼동 관련 판례)(★)-(2017후2178, 2010후3462 등)

(1) 판례의 태도

각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반 수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 한다.

(2) 소결

5. 상당한 주의를 한 것인지 여부(★)

(1) 상당한 주의의 판단기준

상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다고 보아야 한다.

(2) 소결

상당한 주의 X

6. 119조4항/122조 2항 - 사용중단은 취소사유에 영향 X

7. 설문(1)의 해결 - 인용 심결

II. 설문(2)에 대하여

1. 전용사용권 등록의 효력 - 2012년 시행 개정법(★)

2. 설문(2)의 해결 - 부당함

III. 설문(3)에 대하여

1. 상당한 주의의 판단기준(★): (전술하였으나, 제120조는 제119조제1항제2호의 예비적 청구임을 고려하여 한번 더 서술)

2. 제119제4항(★): 사용중단 주장은 부당

3. 결론 - 인용

4. 피청구인 적격 (보론)

- 심판판람 제13판에 제120조의 피청구인을 사용권자로 규정하나, 심판판람은 법령에 해당하지 않아 사법부의 판단을 구속하지 않음
- 행정규칙 중 훈령(법원(法原)성이 없으나 참고 가능)에 해당하는 심판사무취급규정 제25조제1항에 의할 때 피청구인 적격에 하자가 있는 경우 보정명령이 재량으로 발휘될 수 있는데, 당사자의 이익이 없으면 하자는 치유

Comment 피청구인적격에 관하여 오해의 소지가 있어보이나, 출제의 의도는 아닐 것으로 짐작됩니다. 나아가, 설령 출제의 의도였다고 하더라도 재량사항으로서 하자가 치유될 수 있으므로 답안의 결론이 바뀌는 것은 아니고, 보론으로서 추가득점 사항을 보는 것이 적절해 보입니다. 또한, 피청구인적격을 논점으로 잡는 경우에는, 제120조의 의의 및 취지도 함께 서술해 주는 것이 적절합니다.

[문제4]

I. 설문(1)에 대하여

1. 문제의 소재 - 상품별로 구분(★)

2. 2020.1.3 이전(★)

(1) 손실보상청구권의 의의 및 취지

(2) 요건 및 절차, 효과

(3) 사안의 경우

1) [스킨/로션] 서면경고를 수반하였다는 전제 하에 손실보상청구권 행사 가능

2) [티셔츠] 출원상표의 지정상품과 동일, 유사하지 않으므로 손실보상청구권 행사 불가

[여기서 '처갓집' 사건 추가 기술 가능]

3. 2020.1.3 이후

(1) 침해에 해당하는 지 여부 (화장품에 대해서만 침해 성립)

(2) 민사상 조치 - 침해금지청구, 손해배상청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구, 가처분/임시조치 등

(3) 형사상 조치 - 침해죄, 몰수(라벨의 경우 뗄 수 있는 경우 라벨만 분리하여 몰수 가능), 양벌규정

(4) 기타 조치 - 경고/권범심

Comment 기간을 구분하여 손실보상청구권/상표권에 기한 조치를 상술하는 것이 핵심이 될 것으로 생각됩니다. 또한, 사례형 문제임을 감안하여 적용이 되지 않는 조치도 간단하게 적용이 없는 이유를 치고 넘어가 주셔야 합니다.

II. 설문(2)에 대하여

1. 문제의 소재

2. 적법성 - 무효가 명백한 경우 확인의 이익이 존재하는 지 여부(뉴발란스 判例 - 확인의 이익有)(★)

3. 본안

(1) 상표적 사용인지 여부

(2) 보호범위 내에 속하는지 여부 - 상표 유사 판단(뉴발란스 判例- 심결시를 기준으로 판단)

(3) 효력이 제한되는지 여부(★)(재능교육 判例)

4. 심판의 결과 - 티셔츠에 관하여 일부인용

Comment 심판청구의 이익과 본안의 문제를 적절한 배점으로 안배하고, 본안의 문제에서는 등록 후 식별력 취득의 취급을 당사자가 주장한 효력 제한을 중심으로 서술하되, 직권심리를 고려하여 권범심의 다른 심리사항인 상표적 사용 및 보호범위 판단도 함께 서술하는 것이 적절할 것으로 사료됩니다. (출제의 의도가 효력제한에 맞춰져 있다면, 종래 A6 판례와 알파판례 및 재능교육 판례가 대립되고 있다가 뉴발란스 판례에 의하여 정리가 되었다는 내용도 득점을 할 수 있는 부분일 것으로 생각합니다.)